

0006086-75.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... e definitivas pela prática de crimes de furto e tráfico de entorpecentes (autos nº 0000097-14.2018 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2018; autos nº 0014550-80.2015 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. A sentença transitou em julgado em 2018. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2018 e autos nº 0017267-20.2015 - 4ª Vara Criminal da Comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006086-75.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006086-75.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191706/2020 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 12828684 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 485/20/135 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2191706 - 07º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Barbosa de Lima e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

WELLINGTON BARBOSA DE LIMA, ADEMIR FELIX SOARES DOS SANTOS e SILVIO GARCIA ZANI, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 06h15, na Rua Eugênia Sá Vitale, nº. 883,

Taboão, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados entre si e com o corréu RAIMAR JUNIOR PRADO TOMASSETTI (processado nos autos principais nº 1501383-79.2020), com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, para si, 50 (cinquenta) chaves de boca, 80 (oitenta) metros de fios elétricos de telefone, 21 (vinte e um) biscoitos, 24 (vinte e quatro) sabonetes, 4 (quatro) embalagens de farinha de mandioca e 4 (quatro) telefones sem fio da marca Motorola, consoante descrito no Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de págs. 26/27 e fotografias de págs.30/32, bens avaliados em R\$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), nos termos do Auto de Avaliação de págs.28/29, tudo de propriedade da "Cooperativa Industrial dos Trabalhadores em Artefatos Plásticos".

Segundo o apurado, no dia dos fatos, os acusados uniram esforços para o cometimento de crime patrimonial. Para tanto, dirigiram-se ao citado local, onde funciona uma empresa, e conseguiram acessar o seu interior.

Ato contínuo, aproveitando-se da aparente falta de vigilância, os acusados passaram a subtrair fios de cobre, ferramentas, celulares antigos da empresa e produtos alimentícios.

Consigne-se que os acusados ocultaram parcela dos bens nas mochilas que carregavam e outra parte no interior de um veículo que estava dentro da empresa, sendo certo que, para acessar o interior do veículo, eles estouraram o miolo da fechadura e danificaram o seu painel.

Ocorre que, durante a prática criminosa, o alarme da empresa foi acionado e o representante legal da empresa avisado pelo serviço de monitoramento privado. Diante de tais fatos, o representante da empresa acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e logrou êxito em deter os acusados.

O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que a empresa de monitoramento, após ter percebido o acionamento do alarme, avisou ao representante legal da vítima, o qual, por sua vez, ligou para a Polícia Militar, que impediu a consumação do delito.

O delito foi praticado mediante concurso de agentes, na medida em que quatro indivíduos se uniram, em nítida divisão de tarefas, para a prática do delito. Acompanhada por inquérito policial (págs.06/135), a denúncia foi recebida às págs.141/143 em relação aos acusados WELLINGTON E ADEMIR. Frustrado o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público, ante a não localização dos demais acusados, foi aditada a denúncia para inclusão de SILVIO e RAIMAR no pólo passivo da ação, com recebimento às págs.252/253.

Citados por edital (pág.264/265 - Silvio e 289 - Wellington e Ademir), os acusados não compareceram aos autos e tampouco constituíram defensor (págs. 268 e 333). Nos autos principais que seguiram apenas em relação ao réu RAIMAR, que havia sido citado pessoalmente (nº 1501383-79.2020), foi determinado o desmembramento do feito (págs.337/341), ocasião na qual foi decretada a prisão preventiva dos réus WELLINGTON, ADEMIR e SILVIO por descumprimento das medidas cautelares que tinham substituído a prisão preventiva (cf. termos de audiência de custódia de págs.122/125)

Nestes autos desmembrados foi aplicado o artigo 366 do Código de Processo Penal (págs. 355).

Os mandados de prisão foram cumpridos em 19/05/2022 (págs. 458/461 - WELLINGTON), 27/05/2022 (pág. 393/395 - ADEMIR) e 16/06/2022 (págs. 472/474 - SILVIO), realizando-se as audiências de custódia (págs.370/374, 425/426 e 463/464).

Citados pessoalmente às págs. 362, 493, 495 e 503, o feito prosseguiu. Respostas à acusação foram apresentadas às págs. 380 e 507. Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.381/382 e 508/509), em instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, interrogando-se os acusados. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Bruno Fonseca Santos.

Em debates, a acusação requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Postula a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena de Ademir e Wellington, reconhecidos antecedentes criminais e reincidência; e aberto para o réu

Silvio, com aplicação do artigo 44 do Código Penal. A defesa postula a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória. É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelos autos de exibição, apreensão e entrega de págs. 26/27 e avaliação de pág. 28/29, pelas fotografias de págs. 30/32, bem como pelo laudo pericial de págs. 180/189 (local dos fatos).

A existência do crime também vem consubstanciada nas declarações do representante legal da empresa-vítima José Augusto Correia, que confirmou a ocorrência do furto e trouxe elementos relevantes sobre a autoria dos acusados:

Diante de inúmeras invasões anteriores, contrataram a empresa de segurança patrimonial Verisure e, na data do fato, o alarme foi acionado por duas vezes. Na primeira vez, no início da madrugada, a Polícia Militar foi acionada, realizou vistoria no local, mas nada encontrou. Na segunda ocasião, por volta de 05h00, a empresa lhe contatou porque novamente o alarme havia disparado. A Polícia Militar foi acionada.

Dirigiu-se ao local e franqueou a entrada aos policiais militares, meia hora depois. Não havia sinal de arrombamento de obstáculo (acredita que os agentes pularam muro ou portão, de fácil acesso). Em vistoria, quatro indivíduos foram surpreendidos na região do almoxarifado. Inquiridos, nada disseram.

Os furtadores já tinham separado ferramentas, produtos alimentícios, dentre outros objetos descritos na denúncia. Buscavam colocar as mercadorias no interior do carro da própria empresa, um Fiat/Doblo. Para tanto, os criminosos danificaram miolo da porta e painel para tentar ligação direta.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de furto, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Os quatro indivíduos presos no interior da empresa são os réus WELLINGTON BARBOSA DE LIMA, ADEMIR FELIX SOARES DOS SANTOS, SILVIO GARCIA ZANI E RAIMAR JUNIOR PRADO TOMASSETTI (condenado nos autos principais nº 1501383-79.2020).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (págs. 33 - Silvio, 48 - Wellington e 64 - Ademir), em Juízo os réus confessaram a prática do delito nos termos da denúncia:

Sob efeito de droga, pularam o muro do estabelecimento e separaram os bens indicados na denúncia, colocando-os no interior do automóvel da própria vítima, que estava estacionado no galpão, após o réu Wellington estourar o miolo e painel, quando foram surpreendidos pelos policiais militares. O corréu RAIMAR era o quarto furtador e também estava no interior do galpão.

Os réus confessaram na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias

constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada, ademais, pelo depoimento do policial militar Eduardo de Sales Vieira, que em relato coeso e harmônico com anterior, informou os passos da diligência encetada na data dos fatos e a prisão dos acusados:

Recebeu, via COPOM, a informação de que o alarme da Cooperativa, pela segunda vez naquela madrugada, tinha sido acionado. Na primeira ocasião, nada irregular havia sido constatado. Por volta de 06h00, então, a equipe policial dirigiu-se ao galpão, onde já era aguardada pelo representante legal.

Franqueada a entrada, ausente sinal externo de arrombamento (que sugeriu escalada do portão/muro de entrada), a equipe realizou vistoria, dividindo-se no interior do galpão, e surpreendeu quatro indivíduos que agiam com o mesmo propósito, ou seja, a subtração de diversos objetos que já estavam separados em sacolas e em carrinho de mão. Pretendiam transportá-los no veículo Fiat/Doblo da própria vítima, estacionado ali, sendo que o miolo e o painel já tinham sido danificados.

Inquiridos, os agentes nada declararam.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

Ao cabo da instrução, a qualificadora prevista no inciso IV, do §4º do artigo 155 do Código Penal, ficou comprovada.

A comparsaria entre os acusados e o corréu Raimar, vem evidenciada pela forma de atuação, ou seja, em conjunto, com plena aderência de vontades e divisão de tarefas, cada qual fazendo sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo. O crime de furto não ultrapassou a esfera da tentativa.

O laudo do local do fato demonstra que, para ingressar no estabelecimento, os agentes escalaram muro por portão de entrada do imóvel, ingressaram no galpão, separaram 50 (cinquenta) chaves de boca, 80 (oitenta) metros de fios elétricos de telefone, 21 (vinte e um) biscoitos, 24 (vinte e quatro) sabonetes, 4 (quatro) embalagens de farinha de mandioca e 4 (quatro) telefones sem fio da marca Motorola, sendo que parte já estava dentro de bolsas e sacolas (cf. imagens de págs.30/32). Ainda pretendiam subtrair o automóvel da Cooperativa, o Fiat/Doblo estacionado no galpão, no qual colocariam os bens subtraídos. Para tanto, estouraram miolo da porta e painel para possibilitar entrada e ligação direta (imagens no laudo do local do fato, às págs.180/189).

Não lograram consumir o delito por circunstância alheia às suas vontades, pois o alarme da empresa foi acionado e a Polícia Militar contatada, tendo, os réus, sido surpreendidos ainda no interior da empresa.

Não há crime impossível.

O meio empregado pelos agentes não foi inidôneo.

Os policiais militares ou o representante legal da vítima em momento algum interferiram na conduta dos acusados ou de seu comparsa, que agiram espontaneamente e, se não tivessem sido surpreendidos em ação, teriam tranquilamente consumado o delito.

A ação dos milicianos apenas interferiu no iter criminis, impedindo a consumação do delito por circunstância alheia à vontade dos agentes, o que configura a tentativa. O método utilizado pelos réus se mostrava plenamente capaz de atingir seu objetivo, de modo que não se pode identificar, na espécie, a ineficácia absoluta do meio empregado.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem entendido que:

"No crime impossível, enquanto se desenrola a ação do agente ela não sofre interferência alheia, ao passo que na tentativa quase sempre a ação é interrompida por injunção externa.

Nesta, também, o resultado delituoso é sempre possível, porque os meios empregados são, por sua natureza, idôneos, e o objeto contra o qual dirigiu sua conduta é 'um bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão', ao passo que, naquele, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios, isto é, a bens jurídicos que não comportam ofensa ou perigo de ofensa, inviabiliza o resultado delituoso" (Rel. JOSÉ HABICE - RJDTCRIM 08/100).

Não incide, na espécie, o princípio da insignificância, ante a inexpressividade do valor do bem subtraído, que não é o caso dos autos (bens avaliados em R\$ 926,00).

Ademais, ausentes os requisitos (STF - HC 98.152, rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.06.09; HC 97.012-RS, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, v.u., j. 09.02.10; HC 97.772-RS, 1ª T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.11.2009, v.u.; RHC 103552/DF, 2ª T., rel. Min. Eros Grau, j. 01.06.10, v.u.; HC 96757/RS, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.09, v.u.; STJ HC 83.027-PE, 6ª T., Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 16.09.09, v.u) estabelecidos pela jurisprudência para o reconhecimento da causa excludente de tipicidade.

Ora, a conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, tratando-se de furto praticado de forma premeditada e audaciosa e em comparsaria.

Os agentes escalaram muro ou portão de aproximadamente 2,40m, separaram inúmeros bens, estouraram miolo e painel do carro da empresa para, juntamente com as mercadorias separadas, empreender fuga.

Portanto, não presentes mínima ofensividade da conduta da agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não incide a benesse prevista no artigo art.155, §2º, do Código Penal.

Os réus Ademir e Wellington são reincidentes.

Silvio, embora primário, após a prática deste delito se envolveu em outro delito de furto (autos nº 1500738-81.2021, 2ª Vara Criminal de Diadema, cf. certidão criminal de págs. 312/313). O reconhecimento da benesse implicaria impunidade e incentivo à reiteração da conduta.

E não é só. Para ingressar no imóvel, os furtadores escalaram muro de aproximadamente 2,40m, revelando acentuado propósito delitivo. Os agentes separaram inúmeros pertences, colocando-os em mais de uma mochila, e na posse deles abasteciam veículo da própria Cooperativa, com o qual pretendiam fugir, após danificar miolo e painel. As circunstâncias da ação criminosa, retratadas nas imagens do laudo pericial de págs.180/189, apontam conduta social que não se coaduna com a benesse. O reconhecimento do furto privilegiado, na espécie, implicaria impunidade e incentivo à reiteração da conduta.

Não se olvida que os réus se declararam usuários de droga, apresentando tal circunstância para justificar a conduta.

Ainda que fosse adotada como verdadeira, a premissa não tem o condão de afastar a culpabilidade dos réus.

Em Juízo, não apresentaram indicativo apto a revelar comprometimento da capacidade cognitiva em razão do uso de substância entorpecente ou álcool. Pelo contrário, revelaram-se lúcidos e eloquentes, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura.

Nos autos não há prova de alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química.

Conforme preceitua o art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, “segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime” (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Dessarte, os acusados realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado SILVIO, que na época dos fatos era primário e não ostentava antecedentes criminais. Fixo a pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Quanto aos réus WELLINGTON e ADEMIR, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis, pois ostentam condenações anteriores e irrecorríveis.

WELLINGTON foi condenado irrecorrivelmente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação dolosa (autos nº 0002590-79.2005 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2006. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2013; autos nº 0005331-87.2008 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Diadema – a sentença transitou em julgado em 2008. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2013 e autos nº 0011817-48.2005 – 5ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em julgado em 2011. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2013).

ADEMIR ostenta condenações anteriores e definitivas pela prática de crimes de furto e tráfico de entorpecentes (autos nº 0000097-14.2018 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2018; autos nº 0014550-80.2015 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. A sentença transitou em julgado em 2018. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2018 e autos nº 0017267-20.2015 – 4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017).

As desfavoráveis condições subjetivas dos agentes não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena. Assim, elevo a pena-base dos réus WELLINGTON E ADEMIR em 1/5, o que perfaz 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, em relação ao réu SILVIO, não incidem agravantes. Embora presente a confissão espontânea (CP, art.65, III, "d"), deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Presente a agravante da reincidência dos réus aos réus WELLINGTON (autos nº 0029071-82.2015 – crime de furto - 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 20/11/2017. Réu em cumprimento de pena em regime aberto desde 28/07/2017, cf. certidão criminal às págs.441/445) e ADEMIR (autos nº 1500631-78.2018 – crime de roubo - 4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 02/06/2020. Réu em cumprimento de pena em regime aberto desde 12/05/2020, cf. certidão criminal às págs.446/451) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, "d"), opera-se a compensação. Fica mantida a pena acima fixada.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da

confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes:

"A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do ERESp n.

1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem.

O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não incidem causas de aumento de pena.

Reconhecida a tentativa, pondero o iter criminis percorrido pelos acusados.

O laudo do local do fato (págs.180/189) demonstra que, para ingressar no estabelecimento, os agentes escalaram muro ou portão de entrada do imóvel, ingressaram no galpão, separaram 50 (cinquenta) chaves de boca, 80 (oitenta) metros de fios elétricos de telefone, 21 (vinte e um) biscoitos, 24 (vinte e quatro) sabonetes, 4 (quatro) embalagens de farinha de mandioca e 4 (quatro) telefones sem fio da marca Motorola, colocando parte dos bens em sacolas (cf. imagens de págs.30/32).

Prepararam-se para deixar o local no automóvel da própria Cooperativa, o Fiat/Doblo estacionado no galpão, no qual colocavam os bens quando foram surpreendidos pelos policiais militares acionados pela empresa de segurança. Para tanto, estouraram miolo da porta e painel do carro para possibilitar entrada e ligação direta (imagens no laudo do local do fato, às págs.180/189). Não lograram consumir o delito por circunstância alheia às suas vontades, acionado o alarme.

Assim, reduzo a reprimenda no patamar mínimo de 1/3, fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa para o acusado SILVIO; e em 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 08 dias-multa para os réus WELLINGTON E ADEMIR.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica dos acusados, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para o acusado SILVIO, fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, com as condições do artigo 115 da Lei das Execuções Penais.

O reiterado envolvimento do acusado em crimes patrimoniais denota que a aplicação das benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

São institutos que demandam autodisciplina, predicado que o acusado demonstrou não possuir, de modo que as medidas não são socialmente recomendáveis, não preenchidos os requisitos subjetivos.

Com efeito, como acima visto, beneficiado com a liberdade provisória em custódia, neste feito (págs.122/125), o réu voltou a se envolver com o crime patrimonial de furto (autos nº 1500738-81.2021 - 2ª Vara Criminal de Diadema, cf. Certidão

criminal de págs.312/313) e deixou de cumprir as medidas cautelares que substituíram a prisão preventiva.

Aos réus WELLINGTON E ADEMIR, para início de cumprimento da pena fixo o regime inicial fechado.

É o adequado para a consecução das finalidades da sanção penal, considerada a personalidade voltada para a prática ininterrupta de crimes, circunstância que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Não existe relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Na espécie, a prática REITERADA de crimes pelos réus, que os adotou como meio de vida, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando os agentes à modalidade mais severa. WELLINGTON ostenta quatro condenações anteriores e definitivas pela prática de crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação dolosa e furto (autos nº 0002590-79.2005 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2006. A pena foi extinta pelo cumprimento em 2013; autos nº 0005331-87.2008 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2008. Pena extinta pelo cumprimento em 2013, autos nº 0011817-48.2005 - 5ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2011. Pena extinta pelo cumprimento em 2013 e autos nº 0029071-82.2015 - crime de furto - 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 20/11/2017. Réu em cumprimento de pena em regime aberto desde 28/07/2017, cf. certidão criminal às págs.441/445).

ADEMIR ostenta quatro condenações anteriores e definitivas pela prática de crimes de furto, roubo e tráfico de entorpecentes (autos nº 0000097-14.2018 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2018; autos nº 0014550-80.2015 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema. Trânsito em julgado em 2018. Pena extinta pelo cumprimento em 2018; autos nº 0017267-20.2015 - 4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017 e autos nº 1500631-78.2018 - 4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 02/06/2020. Réu em cumprimento de pena em regime aberto desde 12/05/2020, cf. certidão criminal às págs.446/451).

Ambos ainda cumpriam pena anterior quando voltaram a delinquir.

Ademais, em que pese o total da reprimenda, a reincidência impede a fixação do regime mais brando, por expressa determinação legal, a teor do artigo 33, §2º e atendidos os parâmetros do artigo 33, §3º do Código Penal, prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência.

A fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a subtração de coisa alheia móvel.

A Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para permitir ao(à) Juiz(iza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas em razão da maior reprovabilidade da conduta do agente, diante de suas desfavoráveis condições subjetivas, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem

informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus:

a) WELLINGTON BARBOSA DE LIMA, qualificado às págs. 61/62, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 dias multa, no valor unitário mínimo;

b) ADEMIR FELIX SOARES DOS SANTOS, qualificado às págs. 69/70, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 dias multa, no valor unitário mínimo;

c) SILVIO GARCIA ZANI, qualificado às págs. 45/46, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 06 dias multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

Ao cabo da instrução, o réu SILVIO foi colocado em liberdade (págs.518/519), expedindo-se alvará de soltura clausulado, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva.

WELLINGTON e ADEMIR não poderão recorrer em liberdade, pois permanecem os pressupostos e requisitos da prisão preventiva (decretada a prisão preventiva dos réus às págs. 337/341).

Na hipótese vertente, o *fumus commissi delicti* vem consubstanciado nas declarações da vítima, no depoimento do policial militar, na confissão judicial dos acusados e na presente condenação.

O *periculum libertatis* vê-se configurado nas desfavoráveis condições subjetivas dos acusados, que se dedicam à prática ininterrupta de crimes e são reincidentes. O delito apurado nestes autos não configura mero desvio na vida dos réus, que demonstram periculosidade diferenciada. Os réus ostentam, cada um, quatro condenações anteriores e definitivas. E ainda cumpriam penas anteriores quando voltaram a delinquir.

Há fortes indícios de que, em liberdade, reiterarão a conduta. Mister garantir a ordem pública.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, pois não suficientes e adequadas à espécie, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do acusado para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se o necessário e recomende-se os réus WELLINGTON e ADEMIR na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art.

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República.

Junte-se cópia desta sentença nos autos principais (nº 1501383-79.2020), tornando-os conclusos.

Custas pelos réus, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei nº. 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA